

1500716-77.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500716-77.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500716-77.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2095071/2021 - DEL.POL.ITAPEVI, 17208412 - DEL.POL.ITAPEVI, 916/21/407 -

DEL.POL.ITAPEVI, 916/2021 - DEL.POL.ITAPEVI, 2095071 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ARRUDA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

GABRIEL ARRUDA DA SILVA e LEANDRO CASSIO RIBEIRO, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. LEANDRO CASSIO RIBEIRO foi, ainda, denunciado como incurso no art. 307 do CP.

Isso porque, no dia 08 de abril de 2021, às 01h30min, na Rua Afeganistão, altura do n.º 352, Centro, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, pouco depois das circunstâncias de tempo e local acima descritos, na

Delegacia de Polícia de Itapevi, o réu Leandro Cassio Ribeiro atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Os réus foram notificados (f. 116 e 118) e apresentaram defesa prévia (f. 119-125 e 171-177).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 20 de janeiro de 2022 (f. 184-185). Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 200-202). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 200).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Em relação ao acusado Leandro Cássio Ribeiro há, ainda, a imputação relativa ao delito do art. 307 do CP.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 10-11, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse dos acusados, bem como um rádio transmissor.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 107-109), sendo que o resultado foi positivo para "crack", "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, tem-se que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando uma pessoa se aproximou da viatura e informou que numa rua próxima dali havia quatro indivíduos traficando drogas. Dirigiram-se ao local e avistaram os sujeitos com as características informadas. Quando avistaram a viatura, três indivíduos se evadiram e o réu Leandro Cassio Ribeiro permaneceu no local, em posse de um rádio transmissor. Perseguiram os demais indivíduos e lograram êxito em prender um deles, o denunciado Gabriel Arruda da Silva, que estava em posse de uma bolsa que continha drogas em seu interior. Levaram, então, os acusados para a delegacia. No local, em um primeiro momento, o réu Leandro Cassio Ribeiro alegou ser menor de idade e passou dados qualificativos que não eram localizados no sistema. Pouco depois, ele forneceu os dados corretos e disse que havia passado dados errados pois saíra da prisão há pouco tempo e não queria se comprometer.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais militares de incriminar injustamente os acusados. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais militares, permitem presumir que as drogas apreendidas com os acusados se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

Os réus estavam juntos no local, e um deles possuía um rádio transmissor – objeto tipicamente utilizado por traficantes para se comunicarem uns com os outros e avisarem a chegada de policiais. Ainda, um deles estava na posse de quantidade e variedade de entorpecentes incompatível para a figura de um simples usuário. A par disso, estavam em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas. Certamente estavam ali para o fim de vender drogas na região.

Nesses termos, nota-se que as negativas dos réus em nada desqualificam a versão dos policiais militares, já que ausentes relatos contrapostos ou contraditórios.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da circunstância privilegiadora, prevista no art. 33, §

4.º, da Lei n.º 11.343/2006, revendo posicionamento anterior e tendo em vista os recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, não vislumbro inconstitucionalidade na incidência da causa de diminuição de pena. Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação da privilegiadora ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, há que se diferenciar as circunstâncias fáticas e jurídicas dos dois réus.

No que tange ao denunciado Leandro Cassio Ribeiro, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu havia sido beneficiado com liberdade provisória há menos de dois meses quando foi preso novamente pela prática, em tese, do mesmo delito que anteriormente: tráfico ilícito de entorpecentes (f. 198-199).

Isso indica a sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a incidência da

circunstância privilegiadora.

Por outro lado, o réu Gabriel Arruda da Silva é primário, possui bons antecessores, era menor de 21 anos na data dos fatos e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Cabível, portanto, apenas em relação a ele, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Quanto ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP), imputado ao réu Leandro Cassio Ribeiro, a existência do fato e sua autoria também restaram suficientemente demonstradas nos autos.

O réu, em seu interrogatório, confessa ter fornecido nome errado aos policiais no momento de sua prisão, à alegação de que havia sido beneficiado com liberdade provisória há pouco tempo e ficou com medo de ser agredido pelos policiais e de ser preso novamente.

Os policiais, em seus depoimentos prestados em juízo, também confirmam os fatos descritos na exordial acusatória. Afirmam que, no momento da prisão, o réu forneceu dados qualificativos errôneos, que não constavam no banco de dados da Delegacia. Pouco depois, já na Delegacia de Polícia, forneceu os dados corretos para sua identificação.

Importante frisar que o delito tipificado no art. 307 do CP é formal, de modo que sua consumação se dá no momento em que o agente atribui a si mesmo falsa identidade, independentemente de obter alguma vantagem ou causar dano a outrem. Assim, a tão só conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial já caracteriza o delito.

A par disso, a intenção de autodefesa não descaracteriza o delito. Confirma-se, no ponto, o enunciado da Súmula n.º 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

A propósito:

TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO, NO TOCANTE AO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS, E DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 307 DO CP - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO - FORNECIMENTO DE NOME FALSO - CRIME FORMAL - CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DO EFETIVO BENEFÍCIO OU DANO OCASIONADO A OUTREM - SÚMULA 522 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. CORRUPÇÃO ATIVA - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - OFERECIMENTO DE DINHEIRO COMPROVADO NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL SEGURA - CRIME FORMAL QUE SE CONFIGURA COM A PROMESSA OU OFERTA DE VANTAGEM ILÍCITA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. (TJSP, Apelação Criminal 1500724-43.2021.8.26.0567, 1ª Vara Criminal, Rel. Jayme Walmer de Freitas, julgamento: 15/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO E FALSA IDENTIDADE - Materialidade e autoria que decorrem da prova documental e oral - Alegada atipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade para se eximir da responsabilização criminal - Descabimento - Fatos que extrapolam o direito a não autoincriminação - Uso de falsa identidade perante autoridade policial que não configura autodefesa capaz de excluir a antijuridicidade do comportamento - Inteligência da Súmula 522 do STJ - Crime impossível - Inocorrência - Condenação mantida - Pena-base relativa ao furto adequadamente exasperada - Crime cometido em escada rolante, pondo a integridade física da vítima, que chegou a cair e perder a consciência, em risco - Ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena - Substituição da pena e fixação de regime prisional aberto que não cedem margem para abrandamento - Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0094731-08.2018.8.26.0050, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, julgamento: 07/03/2022)

Presentes, portanto, provas bastantes para a condenação em relação ao delito de falsa identidade.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas dos acusados ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com vontade e consciência, traziam consigo as

porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar. Em relação ao acusado Gabriel Arruda da Silva incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, já que não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Outrossim, há subsunção da conduta do réu Leandro Cassio Ribeiro ao tipo penal do art. 307 do CP, porque, com vontade e consciência, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Os fatos são ilícitos, pois reprovados pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

Os denunciados eram maiores de 18 anos de idade (imputáveis), tinham potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhes exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para: (a) condenar o réu GABRIEL ARRUDA DA SILVA nas sanções do art. 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/06; e (b) condenar o réu LEANDRO CASSIO RIBEIRO, já qualificado, nas sanções dos arts. 307 do CP e 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69).

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de

drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Essas considerações referem-se à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Quanto aos demais delitos – no caso dos autos, o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), o raciocínio a ser aplicado é aquele em que as circunstâncias judiciais devem ter um peso de 1/8 do intervalo da pena constante do preceito secundário do tipo penal – tal como acima explanado.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, os acusados são tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. Por outro lado, importante ressaltar que, em seus interrogatórios, afirmaram ser usuários de drogas e consumi-las com frequência. Tal circunstância é desfavorável à conduta social dos denunciados, já que, além de traficarem drogas, financiam indiretamente esse delito equiparado a hediondo. Nesse contexto, tem-se que tal circunstância judicial apresenta-se negativa.

Além disso, as circunstâncias do delito de tráfico também são desfavoráveis. Com efeito, os denunciados estavam na posse de entorpecentes de naturezas diversas, maconha, cocaína e crack, essa última de altíssimo poder destrutivo. Outrossim, a quantidade dos entorpecentes apreendidos foi significativa (3,7g de crack, 79,2g de cocaína e 457,5g de maconha – f. 108-109).

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis aos réus, ou são normais aos tipos penais.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais preponderantes negativas em relação ao tráfico e uma desfavorável no que tange à falsa identidade, fixo as penas bases em: (i) 8 anos e 4 meses de reclusão – e 833 dias-multa para ambos os réus quanto ao tráfico de drogas; e (ii) 4 meses de detenção para o crime de falsa identidade.

Na segunda fase, há a atenuante da menoridade relativa para ser considerada em relação ao acusado Gabriel Arruda da Silva, nos termos do art. 65, I, do CP, tendo em vista que era menor de 21 anos de idade na data dos fatos.

Assim, ante a atenuante da menoridade relativa do réu Gabriel Arruda da Silva, reduzo a sua reprimenda em 1/6, fixando-a, provisoriamente, em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão – e 694 dias-multa.

Quanto ao réu Leandro Cassio Ribeiro, à míngua de agravantes ou atenuantes, mantenho a pena do delito de tráfico tal como acima estipulada, provisoriamente.

Na segunda fase da dosimetria da pena do delito de falsa identidade, há a atenuante da confissão espontânea para ser considerada, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que o acusado confessou em juízo a prática desse crime. Assim, diminuo a reprimenda em 1/6, fixando-a provisoriamente, em 3 meses e 10 dias de detenção.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas em relação ao réu Leandro Cassio Ribeiro, fixo as reprimendas, agora definitivamente, em: a) 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa para o delito de tráfico; e b) 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção para o delito de falsa identidade.

Em relação ao acusado Gabriel Arruda da Silva, na última fase, incide a privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois é primário, possui bons antecedentes e não ficou demonstrada sua dedicação a atividades criminosas, tampouco sua integração em organizações criminosas.

Nesse passo, e considerando a variedade das drogas encontradas em seu poder, tem-se que a pena deve ser reduzida em 4/9. Dessa forma, fixo a reprimenda, agora

definitivamente, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão - e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Destarte, e aplicando a regra do art. 69 do CP, ficam assim estabelecidas as reprimendas, definitivamente: (i) para o acusado Leandro Cassio Ribeiro: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção - e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa; e (ii) para o réu Gabriel Arruda da Silva: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão - e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira dos denunciados, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade do réu Leandro Cassio Ribeiro.

Considerando o quantum da reprimenda fixada e o fato de o delito de tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, embora grave, não ser crime equiparado a hediondo (Tema Repetitivo n.º 600 do STJ), fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado Gabriel Arruda da Silva.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais.

Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Não havendo razões cautelares que demandem a custódia cautelar do denunciado Gabriel Arruda da Silva, poderá ele recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Por outro lado, mantenho a custódia provisória do denunciado Leandro Cassio Ribeiro, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade.

Recomendo o réu na prisão onde se encontra. Expeça-se a guia de execução provisória.

Incabível em relação a ele, aliás, a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

No que concerne ao réu Gabriel Arruda da Silva, de outra feita, presentes os requisitos legais, e sendo a medida adequada e socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo juízo da execução, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de cinco salários mínimos federais, tendo em vista que as das drogas apreendidas são de alto poder destrutivo, necessitando de resposta mais enérgica da Justiça Pública.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelos réus (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estarem

litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhes fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeçam-se as guias de execução definitivas;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA